

1500143-43.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... na equipe, apurando denúncia de tráfico de drogas, inclusive, havia denúncia formal e informal, indicando local de tráfico de drogas, um beco que na verdade é uma rua sem saída. Já era de conhecimento de tráfico no local antes das denúncias chegaram à Delegacia. Conforme estratégia comum do traficando ele tenta sempre se esquivar da ação policial. Numa dessas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-43.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-43.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS THEODORO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUCAS THEODORO DA SILVA, qualificado à fl. 08, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 10h20min, na Rua Oreste Bortoluzzi, nº 145, bairro Nossa Senhora da Paz, no município de Álvares Machado, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado guardava e tinha em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, acondicionada em forma de tablete, com peso líquido aproximado de 48,21g (quarenta e oito gramas e vinte e um centigramas - lacre nº 0033975), e 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,19g (dezenove centigramas - lacre nº 0033976), conforme boletim de ocorrência de fls.

09/14, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, fotografias de fls. 20/23, constatação prévia de substância entorpecente de fls. 24/25, exame químicotoxicológico definitivo às fls. 86/88 e laudo pericial dos objetos de fls. 91/94. Segundo se apurou, o denunciado LUCAS THEODORO DA SILVA adquiriu as porções de drogas acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a guardá-las e mantê-las em depósito em sua residência com vistas a comercializá-las ilicitamente. Na data dos fatos policiais civis dirigiram-se à Rua Oreste Bortoluzzi, nº 145, bairro Nossa Senhora da Paz, no município de Álvares Machado, a fim de aferir a veracidade da informação anônima nº T2202071254, recebida no dia 07/02/2022 através do Disque-Denúncia (fls. 15/17), que apontou a ocorrência de tráfico de drogas no endereço supracitado, onde se depararam, inicialmente, com Valdeci José da Silva, saindo da casa visada, o qual se identificou como usuário de droga e disse que ali estava para adquiri-la, contudo, não logrou êxito no seu intento por falta de dinheiro. Na residência delatada foram recebidos pela adolescente Jéssica Natiele Rosa dos Santos, identificada como companheira do denunciado LUCAS, que franqueou a entrada aos policiais civis. LUCAS, ao notar a presença dos agentes públicos, correu para o fundo do imóvel, mas logo foi detido e com ele localizaram a quantia de R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em dinheiro, em notas variadas, no bolso de sua bermuda, sem comprovação de origem lícita. Em revista ao interior da aludida residência policiais civis localizaram, sobre o sofá da sala, uma bandeja com embalagens plásticas e navalhas com resquícios de drogas, além de uma balança de precisão (fls. 91/94), e 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,19g (dezenove centigramas – lacre nº 0033976), indicando recente fracionamento de substâncias entorpecentes. No interior de um quarto, ao lado da cama de casal, foi encontrado um tijolo de maconha, com peso líquido aproximado de 48,21g (quarenta e oito gramas e vinte e um centigramas – lacre nº 0033975). No mesmo ambiente foram localizados e apreendidos, ainda, R\$ 5.103,00 (cinco mil, cento e três reais) em dinheiro, em notas e moedas variadas, sem prova de procedência lícita, além do aparelho de telefone celular do denunciado. O imputado admitiu que traficava drogas (fl. 08). Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando a denúncia anônima que indicou o endereço do denunciado como ponto de tráfico de drogas, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, adquiridas de pessoa até o momento não identificada, além de petrechos para fracionamento e acondicionamento de drogas para venda, presença de resquícios de droga na balança apreendida (fls. 91/92), afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio espúrio.”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 148/153), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 157/160), o despacho de fls. 183/187, de 19 de maio de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 235/240), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus quanto ao delito de tráfico de drogas, e a absolvição por ausência de provas da estabilidade e permanência quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 241/248), arguiu preliminarmente, a ilicitude da prova angariada aos autos, vez que o ingresso de policiais militares no interior do imóvel residencial do autuado, sem o correspondente mandado de busca e apreensão e sem autorização do réu, foram furtiva, devendo toda a prova colhida no local do delito ser declarada nula e o réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal. No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, em regime aberto, bem como o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade, decorrente de violação ao domicílio, entendo que não há como ser acolhida, visto que se tratando de flagrante delito,

tendo o réu demonstrado nervosismo exacerbado perante a aproximação da Polícia e após verificar a abordagem de Valdeci em frente a sua residência, onde acabara de sair e vindo a confirmar que estava ali para comprar drogas, embora não tinha levado nenhuma pois não havia a droga que comumente usava, corroborando com a denúncia anônima que a Polícia já tinha em mãos, ensejou a efetiva abordagem, com o encontro da droga e a prisão do acusado que confessou amplamente a prática da conduta criminosa, não se mostrando possível alegar a referida garantia constitucional.

No caso dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientes para o afastamento de qualquer alegação de nulidade da prova.

Até porque havia fundadas e sérias razões para se perseguir o réu, diante do seu nervosismo, correndo para dentro da sua residência, e por fim, com a autorização convivente Jéssica, que é inconteste, vez que nenhuma prova a d. Defesa do réu que pudesse rebater o depoimento dos policiais, até mesmo o depoimento de Jéssica que poderia ter confirmado sua autorização, porém, decidiu por não desejar ouvi-la em Juízo, e com isso, encontram as drogas escondida na residência, uma bandeja e navalhas com resquícios de droga, embalagens para embalar a droga, balança de precisão e uma enorme quantia em dinheiro (R\$ 5.230,00), que da forma em que foram localizadas, evidenciam sobremaneira a traficância no local, graças à rápida e eficaz atuação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas.

É conveniente ao réu, chegar perante o Juízo e dizer que ninguém autorizou a entrada da Polícia, vez que nenhuma prova trouxe aos autos que pudessem corroborar com a sua alegação, podendo fazer de qualquer maneira legal, inclusive com vizinhos ou parentes, já que Jéssica, sua companheira estava presente, porém as partes desistiram da sua oitiva, e em solo policial, disse que somente se pronunciaria em Juízo, caindo por terra sua versão escapista, não se podendo conhecer o motivo que em Juízo tenha mudado a sua versão, mas é nítida intenção de se livrar da acusação e desmerecer todo o trabalho da Polícia no combate ao nefasto crime de tráfico de drogas, que vem corrompendo uma multidão de pessoas, e na maioria são jovens, fomentando cada vez mais a prática de crimes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. RECORRENTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES EM DOMICÍLIO ALHEIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade, pela ausência de mandado de busca e apreensão, insta consignar que tanto a jurisprudência desta Corte, como a do eg. Supremo Tribunal Federal, firmaram o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o delito de tráfico de entorpecentes mostra-se prescindível o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. III - No caso, sub examine, no qual se alega a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressar em domicílio alheio teve como elementos precursor e a abordagem realizada em via pública, "[...]momento que encontraram pequena porção de substâncias entorpecentes", bem como informação acerca da existência de mais droga no local em que ela reside, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.

Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. IV - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. V - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos

extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva da ora Agravante, porquanto, consoante se deduz dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, tendo o magistrado primeiramente ressaltado na decisão objurgada que ela "já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (0007559-75.2018.805.0191), onde foi concedida liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão", circunstância que indica a periculosidade concreta da agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC140.998/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020).

É que quando se trata de crime permanente, como o porte de arma e de munição, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal).

A prisão foi feita em conformidade com os ditames legais. O direito em análise não é absoluto, quando há flagrância, pode-se agir, caso contrário, outro tipo de violação poderia ocorrer, até mais grave. "Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC 208957/SP- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - J. 6.12.2011 - DJe 19.12.2011). Cf., ainda, HC 101628/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) - J. 21.10.2008 - DJe 10.11.2008; HC77489/AM- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. 12.2.2008 - DJe 17.3.2008; HC 40056/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Hamilton

Carvalhido - J. 30.6.2005 - DJ 05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO- 5ª do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Gilson Dipp - J. 28.4.2004 - DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP - 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. 1.4.2004 - DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406).

O C. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Tal matéria, todavia, foi suscitada novamente e em reexame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e no julgamento de Habeas Corpus nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no dia 2/3/2021, decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...] 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente [...] (HC 598.051/SP. MATÉRIA CRIMINAL. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª Turma. JULGADO: 02/03/2021. Publ. 15/03/2021).

O Min. Relator Rogério Cruz justificou a decisão da turma em que, somente fundadas razões e desconfiâncias dos agentes do estado, não são suficientes para o ingresso sem mandado judicial na casa do suspeito, e além disso, "deve haver documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado, seja toda registrada em áudio e vídeo, de maneira a não deixar dúvidas quanto a legalidade da ação estatal e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado". Entretanto, tal matéria foi objeto de análise em sede de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e teve como Relator Min. Alexandre de Moraes, que decidiu de acordo com a repercussão geral daquela Corte quando descreve "o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Também ponderou que a TESE é de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.". Sem mais aprofundamento sobre a matéria e esgotada toda e qualquer discussão acerca do tema, merece então trazermos a parte final do julgamento que ocorreu no dia 02/12/2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, conforme segue:

"Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa)[...]."

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19; pela cópia do relatório de denúncia anônima (Disque denúncia) de fls. 15/17; pelo auto de constatação preliminar de fls. 24/25; pelo laudo químico toxicológico de fls. 86/88, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0033975) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 58,6 grama(s) - cinquenta e oito gramas e sessenta centigramas. Massa Líquida: 48,21 grama(s) - quarenta e oito gramas e vinte e um centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0033976 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) retorcido encerrando porção de material sólido petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 4,04 grama(s) - quatro gramas e quatro centigramas. Massa Líquida: 0,19 grama(s) - dezenove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 91/94 que analisou - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 018319 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando uma embalagem de papel de formato retangular possuindo a inscrição "WILKINSON", contendo no seu interior 3 lâminas metálicas com laterais cortantes. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 018320 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando diversos recortes e embalagens plásticas com massa total de 13.44 (treze gramas e quarenta e quatro centigramas). Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 3 (Acondicionado sob o lacre 018317 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando 1 balança, da marca "WELLMIX", usada, em regular estado de conservação. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 4 (Acondicionado sob o lacre 018318 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando 1 (uma) bandeja de plástico de cor bege, de formato ovalado usado, em estado regular de conservação, da marca "PLASLINE". Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 119/131; além da prova

oral carregada para os autos.

Em Juízo, o Policial civil Guilherme Frederico Lima Nomura, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em três policiais na equipe, apurando denúncia de tráfico de drogas, inclusive, havia denúncia formal e informal, indicando local de tráfico de drogas, um beco que na verdade é uma rua sem saída. Já era de conhecimento de tráfico no local antes das denúncias chegaram à Delegacia. Conforme estratégia comum do traficando ele tenta sempre se esquivar da ação policial. Numa dessas averiguações, identificaram um usuário saindo da residência, e em breve diálogo, ele confirmou que estava ali para comprar entorpecentes, e logo que entraram no corredor da residência, encontraram com a convivente do Lucas, e nesse momento, com a sua autorização, ingressaram na residência e um dos policiais já percebeu que havia resquícios de drogas, dinheiro separado, sacos plásticos sobre uma bandeja no sofá da sala. O investigado de imediata confessou que havia drogas, em seu quarto tinha uma porção maior de droga, salvo engano, maconha, realizando a apreensão e diante da confirmação da prática do tráfico, ambos foram encaminhados à Delegacia, tendo a convivente do réu dito que não participava. No local também foi apreendida uma balança de precisão e a quantia maior que R\$ 5000,00, que segundo o réu disse que juntava para comprar uma moto, porém, disse que não trabalhava, achando estranho que teria esse dinheiro sem trabalhar, não convenceu os policiais. Quando o usuário foi abordado saindo da casa do réu, nenhuma droga foi encontrada com ele, pois ele disse que foi para adquirir, mas não teria a droga que ele usava, salvo engano, ele era usuário de crack, e encontraram apenas resquícios de crack na casa.

A testemunha Leonardo de Castro Gusman, Policial Civil sediado em Alvares Machado, sob o crivo do contraditório declarou que no dia dos fatos o flagrante foi tranquilo. Já tinham denúncias que no local era ponto de tráfico de drogas, a região é bastante conhecida por vários meliantes. A equipe se deslocou para averiguação e de imediata já visualizaram um usuário contumaz, conhecido da polícia e resolveram aborda-lo. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ele disse que estava ali para comprar drogas. De imediato já ingressaram no imóvel, no corredor que dá acesso aos fundos, viu um indivíduo correndo e uma moça na área da parte de fora da residência, ele foi em sentido da cozinha enquanto entrou pela lateral esquerda, pois percebeu que por ali dava fuga e quando ele tentou sair pela sala, o abordou. Em revista pessoal, salvo engano, encontrou uma porção de maconha no bolso da bermuda do réu e já ficou evidente que havia vários petrechos para o tráfico de droga, balança, várias embalagens, bastante dinheiro, salvo engano, R\$ 5.000,00, e em conversa com o casal, a moça disse que poderia vistoriar o imóvel, que não teria problema algum, e encontraram porção de crack na sala, e no quarto encontraram um tijolo de maconha ao lado da cama, e o acusado acabou confessando que desde que mudou para aquele local praticava o tráfico, e sobre a companheira que também comercializava, ele disse que não, mas que tinha conhecimento que o acusado praticava. Diante disso, recolheram toda a prova e os conduziram para a Delegacia onde foi ratificada a voz de prisão e lavrado o flagrante.

O réu Lucas Theodoro da Silva, em seu interrogatório declarou que já nunca foi preso ou cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que realmente as drogas lhe pertencem. Ao contrário do que disseram os policiais não correu quando a polícia chegou, no momento estava deitado na sua cama, sua esposa teria acordado para ir até a casa da mãe dela. Quanto a Valdeci, afirma que ele tinha ido em sua casa, pois como usa drogas, sempre dá para ele. E no momento que a Jéssica saiu para ir a casa da mãe dela, os Policiais abordaram o Valdeci e já dizendo para Jéssica ficar com as mãos para trás. Afirma que os policiais não pediram permissão para Jéssica deixa-los entrar em sua casa, pois estava quase ao lado, e quando eles entraram, o pegaram dentro do quarto e já disse a verdade para eles, que tinha sua maconha ao lado da cama e a bandeja que estava no sofá. Afirma que a droga encontrada diz que em Machado, tem a batateira, e vinha juntando dinheiro para comprar uma moto, e nesse dia da abordagem, realmente tinha comprado 50 gramas de maconha e 3 gramas de crack, que esfarelou na bandeja e sempre vendia, ao em torno de R\$ 10,00, as vezes vendia para sustentar seu vício. No dia que Valdeci foi até sua casa, sua esposa disse para ele ir embora porque estava deitado, quando a

Polícia o abordou e entraram em sua residência.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

A prova é firme e segura e apontam que o réu Lucas, tinha em depósito em sua residência para fins de fornecimento a terceiro, a droga que foi encontrada pelos policiais civis durante a operação. Lucas também confirmou que tinha maconha e crack, e que vendia por R\$ 10,00 para sustentar seu vício. Também disse que sempre que tem droga, oferece e dá uma parte para o Valdeci, usuário de drogas, não se soube se gratuitamente ou vendia, entretanto, não é relevante para o processo, tendo em vista o tipo penal contido no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, com sua característica de misto alternativo.

Nesse sentido, confirma-se a veracidade da denúncia feita de forma anônima ao Disque Denúncia, registrada sob nº T2202071254 no dia 7/2/2022 (fls. 15/17), apontando a ocorrência de tráfico de drogas no local indicado, onde a Polícia prontamente, identificou Valdeci saindo do imóvel, porém sem nenhuma droga, mas informou aos policiais que não tinha a droga que usava, tendo os policiais ingressado na residência e encontrado a droga, dinheiro e petrechos para o preparo da droga para venda.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (02 porções, 1 de crack pesando 0,19 gramas e um tijolo de maconha pesando 48,21 gramas), bem como numerário (R\$ 42,00), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que já vinham recebendo relatos de tráfico de drogas no local, que acabam denunciando, mesmo sendo de difícil identificação, acabam por serem descobertos, e exatamente o que aconteceu nos autos, por denúncia anônima se dirigiram até o local indicado e abordaram Valdecir que disse não conseguiu comprar porque não tinha a droga que usa.

Ademais, foi localizado grande quantia em dinheiro, mais precisamente R\$ 5.230,00, em notas e moedas variadas, que o réu não encontrou justificativas, os demais objetos usados para embalar drogas, encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, reforçam ainda mais o conjunto probatório coligido aos autos.

Pelo depoimento coeso e harmônico dos Policiais Civis, fica claramente demonstrada nos autos a conduta típica praticada pelo réu, mormente que, se dirigiram ao local dos fatos aguardando o momento em que abordaram Valdeci que acabara de sair da casa de Lucas, e este afirmou que estava ali para comprar drogas, porém não encontraram nada com ele pois disse que ali não tinha a droga que usava, quando o réu então, ao perceber a presença da polícia, tentou se evadir pelos fundos da residência e empreendido fuga, porém foi alcançado e detido. Acabou por confessar que ali fazia o tráfico de drogas, e não apresentou justificativa para quantia expressiva de dinheiro apreendida em sua residência. Afirmaram que na residência encontraram uma bandeja com resquícios de cocaína, navalha, saquinhos plásticos, balança de precisão tudo para o preparo e embalagem de drogas para posterior venda a usuários. Não é demais lembrar que depoimentos de policiais civis são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Confira-se:



"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 223086/SP DJe 02/12/2013).

"Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)" (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5ª Câmara Criminal Apelação nº 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).

Nesse ponto, "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, mas pela ocorrência dos fatos como informado pela Polícia Civil, além de enorme quantia em dinheiro e petrechos para preparar a droga para venda. Por tudo isso, demonstrada, a saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde foi surpreendido.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 20/23, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa dos réus e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da

privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu guardava e tinha em depósito na residência, grande quantidade de maconha e uma pedra de crack, de onde retirava parte para a venda a terceiro.

No caso dos autos a polícia recebeu denúncia com informações que o réu vinha realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais. Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de manter em sua residência a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006,

no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da

dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do